



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

תיק מס' 250/14

התובעות:

1. יעל קליימן מור

2. אלון אביבה

ע"י ב"כ עו"ד ענת בן דרור

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. צ'רלי ביטון

2. אבי ביטון

3. חנה עובדיה

4. יעל צרפתי

5. בת שבע אלקבץ

כולם ע"י ב"כ עו"ד נוראל דור ועו"ד עמרי דור

פ ס ק - ד י נ

פסק דין זה עוסק בהתנגדות התובעות להרחבת דירת הנתבעים אל עבר תחומי הגג המשותף. במסגרת זו יש להידרש בין היתר, לשאלה האם יש לראות בתובעות כמי שנתנו את הסכמתן נוכח קיומה של "הרחבה דומה" בדירת כל אחת מהן, והאם יש בבניה המבוקשת בכדי לפגוע בזכויותיהן של התובעות, באופן המצדיק כשלעצמו שלא לאפשר את הרחבת דירת הנתבעים.

הערה מקדימה

תביעה זו הוגשה ביום 10.8.14 ונדונה בפני כבוד המפקח הבכיר (כתוארו דאז) ש. הייזלר. כבוד המפקח הייזלר פרש מתפקידו לאחר שמיעת מסכת הראיות בשלמותה ואולם טרם שהיה סיפק בידו ליתן את פסק הדין. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הועבר תיק זה לטיפול.

תקנה 177 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, שעניינה "רציפות הדיון", קובעת כי אם נמנע משופט לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו (ראו: ע"א 534/69 אהרן שושני נ' יפה אלזם, פ"ד כד (1) 145 (1970), בעמ' 147; ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק, פ"ד כז (1) 768 (1973), בעמ' 773; ע"א 387/74 יוסף אברהם נ' בתי מרגוע ומלונות "היוזם" בע"מ, פ"ד כט (1) 353 (1974), בעמ' 356; ע"א 577/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' גלי עטרי, פ"ד נא (5) 241 (1997), בעמ' 249).



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בהחלטתי מיום 5.7.16 התבקשו הצדדים להודיע האם הם מעוניינים להשמיע את עדיהם, כולם או מקצתם, שנית לפניי ואם כן- לפרט טעמיהם לכך. ביום 6.7.16 הודיעו הצדדים כי אינם מעוניינים בכך.

לפיכך, פסק הדין יינתן מבלי שהעדויות שנשמעו בפני כבוד המפקח הייזלר תשמענה פעם נוספת.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית משותף המצוי ברחוב המשמרות 8, שכונה מוסררה (מורשה) בירושלים והידוע כגוש 30054 חלקות 44, 34 ו-55. הבית המשותף מורכב משני מבנים. מבנה I שבו שלוש קומות- בקומה הראשונה דירה אחת, בקומה השנייה שלוש דירות ובקומת הגג דירת חדר אחת (להלן: "מבנה 1"). במבנה II שתי קומות, בקומה הראשונה שלוש דירות ובקומה השנייה דירה אחת (להלן: "מבנה 2"). סך הכל מונים שני המבנים 9 חלקות משנה (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף מתנהל ברישומי חברת "עמידר- החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ" (להלן: "עמידר") והוא טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
2. כל הצדדים להליך זה הם בעלי זכויות בדירות המצויות במבנה 2 של הבית המשותף. התובעת 1 (להלן גם: "קליימן") היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה בתשריטי הבית המשותף בעמידר כדירה מספר 8 (ראה בתשריטים- הן נספח א' לכתב התביעה והן נספח א' לכתב ההגנה- להלן: "התשריטים") דירה זו מצויה בקומה הראשונה של משנה 2 (להלן: "דירת קליימן"). התובעת 2 (להלן גם: "אלון") היא בעלת הזכויות בדירה הרשומה בתשריטים כדירה מספר 6, וגם היא בקומה הראשונה של מבנה 2 (להלן: "דירת אלון").
3. הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הרשומה כחלקת משנה 9 בתשריטים, הממוקמת מעל לדירות התובעות, בקומה השנייה של מבנה 2 (להלן: "דירת הנתבעים").
4. דירת קליימן הייתה במקורה בשטח של 52.6 מ"ר, ולה צמוד מחסן בשטח של 3.8 מ"ר. בסך הכל חלשה דירת קליימן על שטח של 56.4 מ"ר (ראה תשריט- נספח א' לכתב ההגנה). ברבות השנים רכשה קליימן מעמידר בור מים בשטח של 36.4 מ"ר והרחיבה את דירתה תוך הוספת שטח בור מים זה לדירתה (ראה התשריט המצורף כנספח א' לכתב תביעה, בו מצוין גם שטח זה של בור המים ביחס לדירת קליימן). בין הצדדים קיימת מחלוקת באשר לטיב הזכויות שרכשה קליימן, ככל שרכשה, ביחס לאותו בור מים, ועל כך יורחב בהמשך.
5. דירת אלון הייתה במקורה (ראה התשריט המצורף כנספח א' לכתב ההגנה) בשטח של 31.9 מ"ר. במהלך הזמן נוספה גלריה לדירתה בשטח של 32.9 מ"ר (ראה התשריט המצורף נספח א' לכתב התביעה). בין הצדדים ניטשה מחלוקת בכל הנוגע למשמעות הוספת הגלריה ביחס לזכויות אלון, וגם נושא זה יידון בהמשך פסק הדין.
6. דירת הנתבעים היא במקורה, כך על פי התשריטים, בשטח של 124.1 מ"ר. הנתבעים מעוניינים להרחיב דירתם אל עבר גג הבית המשותף, באופן בו תיבנה על הגג קומה נוספת ועליה גג רעפים, בשטח של 134.9 מ"ר. בנושא זה הוגשה לוועדה המקומית בקשתם לקבלת היתר בניה- תיק 0906.01/2012 (להלן: "ההרחבה המבוקשת"). ההרחבה המבוקשת מבוססת על תכנית מס' 3845 ושינוי מספר 1/93 לתכניות מס' 3070, 2902, 3070 א' ו- 3188, 4275, 4337 (ראה נספח ה' לתצהיר עדותה הראשית של קליימן- להלן: "התכנית").



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

7. על אף התנגדות התובעות, אישרה הועדה המקומית את הבקשה. על החלטת הועדה המקומית הגישו התובעות ערר, ובד בבד הגישו ללשכת המפקח על רישום מקרקעין בקשה למתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, שיאסור על הנתבעים או מי מטעמם, לבצע כל תוספת בניה בבית המשותף, וכן את התביעה דנן למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור את ההרחבה המבוקשת לדירת הנתבעים, אל עבר הגג המשותף.

בין נימוקי הבקשה לצו מניעה זמני - הבנייה מצד הנתבעים על גג הבית המשותף תפגע מהותית בזכויות הקנייניות המוקנות לתובעות מכוח אחוזי הבניה היחסיים הקיימים בבית המשותף.

8. ביום 10.8.2014, ניתן צו ארעי האוסר על הנתבעים או מי מטעמם לבצע עבודות בניה בבית המשותף, למעט עבודות בתוך דירתם, והמשך הדיון בתובעה הותנה בהפקדת ערובה, ובנוסף ניתנה זכות תגובה לנתבעים. בדיון שהתקיים ביום 17.9.2014, ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים להותיר את צו המניעה הזמני על כנו, ולהמשיך בבירור ההליך העיקרי.

9. במסגרת ההליך העיקרי הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, התקיים דיון הוכחות והצדדים סיכמו טענותיהם בכתב. כמו כן נערך ביום 17.12.14 ביקור במקום על ידי כב' המפקח הייזלר. במסגרת ביקור זה ערכו הנתבעים מדידות, כאשר הוסכם על רישום פרטי המדידות בפרוטוקול. המדידות שנרשמו הן אלו:

"בחלל העליון של דירת התובעת מס' 1 המרחק בין הרצפה לתקרה הוא 3.07 מ'.

בחלל התחתון של דירת התובעת מס' 1 המרחק בין הרצפה לתקרה הוא 2.40 מ'.

שטח החלל התחתון בדירת התובעת מס' 1 הוא 36.4 מ"ר, והוא משמש למגורים.

בנוסף בדירת התובעת מס' 1 גרם מדרגות ששטחו הוא כ- 7 מ"ר.

בדירת התובעת מס' 2 קיימת גלריה שפיצלה למעשה את הדירה הנ"ל לשתי קומות. גובה הקומה התחתונה הוא 2.70 מ', וגובה הקומה העליונה הוא 2.06 מ'. עובי רצפת הגלריה הוא 27.5 ס"מ.

גובה התקרה בכניסה לדירה זו (לפני המדרגות) הוא 3.4 מ', ולאחר מכן כדי להיכנס לתוך דירה זו יש לרדת במדרגות שגובהן כ- 80 ס"מ"

10. בפרוטוקול הביקור במקום מיום 17.12.14 צוין עוד כי: "הצדדים הסכימו כי מדידות אלו יהוו בסיס לדיון בתובענה דנן".

11. ביום 19.7.16 ערכתי עצמי ביקור במקום, בנוכחות התובעות, הנתבע 2 ובאי כוחם. במסגרת זו התרשמתי באופן בלתי אמצעי מהבית המשותף ותוספות הבניה הנטענות בדירות התובעות.

ב. עיקרי טענות התובעות:

12. התובעות טוענות כי הנתבעים אינם אווזים ברף הנדרש בחוק של הסכמת בעלי הדירות לביצוע הרחבת דירתם (3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהן).

13. לטענת התובעות, מונה הבית המשותף ארבע דירות בלבד (שכן לשיטתן מבנה 2 אינו קשור פיזית או ניהולית למבנה הנוסף, ויש לראות בו בית נפרד לצורך בחינת ההסכמות הנדרשות). היות ובבית משותף בן ארבע



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

דירות דרושה הסכמה של שלושה בעלי דירות לפחות, הרי שלדידן, זכויותיהן ברכוש המשותף הן למעלה ממחצית, ועל כן, הן מהוות למעשה "גוש חוסם קנייני" לקבלת ההסכמה לבניה המבוקשת.

14. התובעות מוסיפות וטוענות כי מאחר והנתבעים כלל לא הציגו הסכמות לבניה המבוקשת, יהיה עליהם לשכנע כי ההרחבות אותן ביצעו התובעות בדירותיהן מהוות "הרחבה דומה". התובעות כופרות בכך שההרחבות בדירתן עולות כדי "הרחבה דומה".

15. לחלופין, כך נטען, ככל שיקבע כי הבית המשותף דגן מורכב משני אגפים ולו תשע חלקות משנה, אזי היה על הנתבעים להוכיח שקיבלו הסכמות של 7 בעלי דירות, על מנת להרחיב את דירתם, וזאת לא נעשה.

16. לטענת התובעות, בביצוע ההרחבה המבוקשת לדירת הנתבעים תיפגענה זכויותיהן הקנייניות משום שכל זכויות הבניה הקיימות לבית המשותף על פי התכנית, ימומשו בעצם על ידי הנתבעים, במקום שהזכויות תחולקנה בין בעלי הזכויות בבית לפי חלקם היחסי. בביצוע ההרחבה המבוקשת, כך טוענות התובעות, תפגענה למעשה זכויותיהן היחסיות בזכויות הבנייה המוקנות לבית המשותף כולו.

17. התובעות מוסיפות וטוענות כי ההרחבה המבוקשת לדירת הנתבעים תיפגע בזכויותיהן הקנייניות בפן נוסף שכן ערכה של דירת הנתבעים יעלה לאין ערוך בעוד שערך דירותיהן ירד.

ג. עיקרי טענות הנתבעים:

18. הנתבעים טוענים כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב, שעה שכל אחת מהתובעות הוסיפה בניה לדירתה והעלתה את ערכה, תוך השתלטות על רכוש משותף ופגיעה בו, בניגוד להוראות התכנית, ובהיעדר היתר בניה כדין. עוד הוסף שהתובעות מגדילות לעשות בדרישתן להגדלת חלקן ברכוש המשותף בשל הבניה הלא חוקית שביצעו.

19. אשר לטענות בדבר ההסכמה הנדרשת להרחבה המבוקשת, טוענים הנתבעים כי הבית המשותף מורכב משני מבנים ועל מנת לחשב את חלקו של כל בעל דירה ברכוש המשותף יש להתייחס לשטח הרצפות של כלל הדירות בבית המשותף – דהיינו בשני המבנים המרכיבים את הבית המשותף, כך שטענת התובעות ל"גוש חוסם קנייני" אינה נכונה.

20. לדידי הנתבעים, קליימן חפרה ובנתה ללא היתר את המרתף, שהיה בעבר בור מים, בדירתה, והפכה אותו בניגוד לדין לשטח למגורים תוך פגיעה בזכויות קנייניות של יתר בעלי הזכויות בבית המשותף.

21. אשר לדירת אלון גורסים הנתבעים, כי אלון הכפילה את שטח דירתה המקורית בבניית קומה נוספת (גלריה), תוך חפירה אל תת הקרקע שמתחת לדירה, סגירת חלק מהחצר המהווה רכוש משותף והפיכתה למבואת כניסה לדירה.

22. הנתבעים טוענים כי לאור הוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 – הרחבת דירותיהן של התובעות מקימה הסכמה קונסטרוקטיבית להרחבה דומה של יתר הדירות בבית המשותף, ועל כן התובעות אשר הרחיבו כאמור את דירותיהן, מנועות מהגשת תובענה זו, ומושתקות מהבעת התנגדות לבניה אותה מבקשים לבצע הנתבעים, ויש לדחות את תביעתן מטעם זה בלבד.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

23. הנתבעים מדגישים כי בהתאם לתכנית החלה במקרקעין, רק בעלי הדירה בקומה העליונה יכולים להרחיב דירתם אל עבר הגג. משום כך, נטען, כלל לא נפגעו זכויותיהן היחסיות של התובעות באחוזי הבנייה הקיימים, שכן ממילא הן לא יכלו לנצלן לצורך הרחבת דירותיהן או לשם הבניה בגג, לפי התכנית התקפה.

ד. דיון והכרעה:

24. במסגרת הדיון עומדות בפני מספר שאלות להכרעה. האחת – האם נתונות לנתבעים הסכמותיהן הקונסטרוקטיביות של התובעות מכוח "הרחבה דומה" של כל אחת מהן בדירתה. השנייה – האם, נוכח המסקנה העולה מבחינת הסוגיה הראשונה, אוזנים הנתבעים בהסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם כנדרש בהוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 לצורך הרחבת דירתם; השלישית – האם בביצוע ההרחבה המבוקשת יש כדי לפגוע בזכויותיהן של התובעות באופן המצדיק שלא להתיר את ביצוע ההרחבה כמבוקש, אף אם יש בידי הנתבעים את הסכמת בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71ב(א) לעיל. הרביעית – האם התביעה הוגשה בחוסר תום לב ומהי נפקותה של הקביעה בהיבט זה.

25. במסגרת זו יש להידרש גם לשאלה מהי "יחידת הבסיס", היינו אותו "בית משותף" אשר ממנו יש לגזור את רף הסכמת בעלי הדירות הדרוש. האם מדובר בשני המבנים או שמא עומד כל מבנה בפני עצמו ומהווה "בית משותף" עצמאי. אפתח בסוגיה הנוגעת לקיומה או היעדרה של "הרחבה דומה" ביחס לדירות הנתבעות. ככל שאמצא כי אין מדובר בהרחבה דומה ממילא אין לנתבעים הסכמת רוב בעלי הדירות אף לא ממבנה 2 ולפיכך יכול ויתיתר הדיון בשאלה האם יש למנות את הסכמת בעלי הדירות משני המבנים יחד, או שמא יש לראות לצורך העניין בכל מבנה כבית משותף נפרד.

26. אקדים את המאוחר ואציין כי במקרה דנן מצאתי כי יש לקבל את התביעה. להלן אפרט נימוקיי.

המסגרת הנורמטיבית

27. ראשית יש להקדים ולציין כי הבית המשותף דנן אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים. עם זאת, אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה. לפיכך, חלות על הבית המשותף הוראות סעיף 11 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") הדן ב- "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים".

28. כלל הקבוע בחוק בכל הנוגע להצמדת חלק מהרכוש המשותף על ידי בעל דירה מסוימת לדירתו הוא שעל מנת לעשות שימוש ייחודי בו, יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף (ר' סעיף 62(א) לחוק).

29. סימן 11 לחוק, מהווה חריג חקיקתי לכלל זה, נוכח הוראת סעיף 71ב לחוק הקובעת, לאמור –

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה..."

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א) חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה בחלקו היחסי ברכוש המשותף...

(הוראות סעיף 71א עד 71ד הוחלו מפורשות, במסגרת סעיף 77ב, גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים).

30. המחוקק התיר אפוא, בחקיקה ספציפית, פגיעה מסוימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף, והוריד את רף ההסכמה הנדרש לצורך הרחבת דירה, בקבעו שיש צורך בהסכמה של 3/4 מבעלי הדירות ש-2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם בלבד.

31. סעיף זה חוקק במסגרת תיקון 18 לחוק המקרקעין משנת 1995, שנועד לצמצם את מצוקת הדיור באמצעות מתן היתר לבעלי הדירות להרחיב את דירתם על שטח הרכוש המשותף, הרחבה הסמוכה פיזית לדירה (ר' ע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא, פורסם ב"נבו", ניתן ביום 2.8.12). ויודגש, הוראות תיקון 18 חלות הן לעניין הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלוגית לשם ביצוע הרחבה, והן לעניין חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לביצוע ההרחבה (רע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ, תק-על 2010(3), 2320, להלן-**"עניין פל"**).

32. הנה כי כן, ככלל, בבואנו לבחון האם בעל דירה זכאי להרחיב את דירתו על שטח הרכוש המשותף, יש לבדוק האם הוא עמד בתנאים הנדרשים בחוק. בתוך כך, יהא עלינו לוודא כי מדובר בהרחבת דירה כהגדרתה בחוק, וכן כי בידי בעל הדירה המבקש להרחיב את דירתו מצוי הרוב הדרוש על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין.

"הרחבה דומה"

33. סעיף 71ב(ג) לחוק קובע, כאמור, כי **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**.

34. הגדרת ה"הרחבה" הקבועה בהוראת החוק כאמור, היא רחבה ביותר: **"...כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש"** (ר' א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', 222).

35. מהי, אם כך, **"הרחבה דומה"** בה דן סעיף 71ב(ג) לחוק?

36. בע"א (מחוזי חיפה) 22123-10-10 זינגר ואח' נ' חדד ואח', פורש המונח **"הרחבה דומה"** ונקבע שם כך:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבנין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.

עצם העובדה שהרחבה שמבקש דייר לבצע ייעודה למגורים, כמו גם ההרחבה שבוצעה על ידי דיירים נוספים בבניין, אין די בה כדי לעמוד בהוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין באשר כל בניית הרחבה המבוצעת בדירה, בין אם מדובר במרפסת, בניצול שטח חדר מדרגות, מחסן ועוד, נועדה בסופו של דבר להרחבת שטח המגורים. יוצא אפוא, כי מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם למגורים.

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה".

37. הנה כי כן, לא נדרשת זהות בין ההרחבה שביצע השכן, לבין הבניה המבוקשת כיום. פרשנות המושג "הרחבה דומה" משמעה – הרחבה מסוג דומה; הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי (ר' גם ע"א (מחוזי י-ם) 3235/02 אביב דוד נ' גדולטר-בכבוד רונית (פורסם בנבו).

38. מבחן היקף ההרחבה הוא מהותי ויש לוודא כי קיים דמיון בין שטחי ההרחבות המבוקשות. כך הסביר זאת המלומד אייזנשטיין – "ראוי להדגיש כי סעיף 71ב(ג) הנ"ל מתייחס להרחבה דומה, כלומר, רואים את מי שדירתו הורחבה בגודל מסוים כמי שהסכים להרחבה של כל דירה אחרת שתהיה בגודל דומה להרחבה שאושרה לו. הגודל הדומה אינו חייב להיות בהכרח מדויק ושווה, אלא יכול להיות גודל דומה ושווה בקירוב..". (ראה: א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 234 (ההדגשה אינה במקור י.ע.ש).

39. עולה, איפוא, כי על מנת לבחון האם הרחבה היא בגדר "הרחבה דומה" יש לבחון את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף כתוצאה מאותה הרחבה. ככל שהיקף הניצול או הפגיעה זהים או דומים, כך ניטה לסבור כי אכן מדובר ב"הרחבה דומה".



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

40. נפנה לבחינת נסיבות המקרה דנן. ראשית נבחן האם הוספת בור המים לדירת קליימן היא בגדר "הרחבה דומה". בהקשר זה יש להידרש תחילה אל הוראות הסכם המכר מיום 14.11.12 בין רשות הפיתוח לקליימן בנוגע ל"עסקת ההשלמה" (ראה נספח ז' לתצהיר קליימן, להלן: "**הסכם המכר**") ולפרשנותו.

41. כאשר עסקינן בפרשנותו של חוזה, עלינו לתת את הדעת הן ללשון החוזה והן לנסיבות כריתתו ולאומד הדעת הסובייקטיבי המשותף של הצדדים לחוזה. "**אומד דעת זה הוא המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים. על אומד הדעת למד הפרשן מלשון החוזה ומהנסיבות החיצוניות לו. שני מקורות אלה 'קבילים' הם. בעזרתם מגבש הפרשן את אומד דעתם המשותף של הצדדים**" (דברי המשנה לנשיא (כתוארו אז) השופט ברק, ע"א 4628/93 **מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ**, פ"ד מט(2) 265 (1995), בעמוד 311- להלן: "**עניין אפרופים**"). הלכה זו נתאשררה לאחר דיון בהרכב מורחב בדנ"א 2045/05 **ארגון מגדלי הירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל**, פ"ד סא (2) 1, 2006 (להלן: "**ארגון מגדלי ירקות**"). לאחר שנפסקו ההלכות בעניין אפרופים וארגון מגדלי הירקות לעיל, נחקק תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "**חוק החוזים**"). הוראת סעיף 25(א) לחוק החוזים קובעת כך: "**חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו**". בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 3961/10 **המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ** (פורסם ב"נבו"), נדון תיקון מס' 2 לעיל, כאשר על רקע בחינת ההלכה הפסוקה, הגיע בית המשפט למסקנה כי בהליך פרשנות החוזה, ביקש המחוקק ליתן משקל משמעותי ללשונו. נוכח המקום המרכזי השמור ללשון החוזה בהליך הפרשני נפסק עוד כי "**ככל שלשון החוזה ברורה יותר, כן תיזדרשנה ראיות-חוץ בעלות משקל כבד יחסית כדי לגבור על הפירוש הנדרש ממנה לכאורה... מישקלן הכולל של ראיות-החוץ חייב שיהא רב למדי עד שיעלה בידיהן לגבור על הלשון הברורה**" (ארגון מגדלי ירקות, פסק דינו של השופט חשין בעמ' 52-53). ראה עוד דיון מקיף שנערך בנושא במסגרת פסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 3894/11 **דלק- חברת הדלק הישראלית בע"מ נ' ניר בן-שלום** (פורסם בתקדין. ניתן ביום 6.6.13).

42. בהסכם המכר הוגדר הממכר כ" **זכויות הבנייה המהוות את זכויות הבנייה לבניית עד 36.4 מ"ר...**" מלשון הפשט של הוראה זו נראה כי נמכרו זכויות בנייה לקליימן (בהנחה שאכן היו בבעלות רשות הפיתוח זכויות בניה באותה עת אותן יכולה למכור). אלא, שלשון ההסכם אינה ברורה דיה ביחס לממכר, כך לא מפורט אם אלו זכויות בניה כלליות או ביחס לבור המים, ואף כלל לא מוזכר בור המים ככזה. לפיכך, יש לבחון את הנסיבות שאפפו את העסקה, כמו גם המטרות, היעדים, האינטרסים, והתכנית אשר הצדדים ביקשו במשותף להגשים.

43. עסקת מכר בור המים באה על רקע גילוי של בור המים תחת דירתה המקורית של קליימן. בהקשר זה העידה קליימן בתצהיר עדותה הראשית כי ערכה שיפוץ בדירתה כאשר "**כשהתחילו את השיפוץ והרימו את הריצוף נתגלה לנו בור מים מתחת לאדמה**" (ראה סעיף 6 לתצהיר עדותה הראשית מיום 5.10.14. ראה גם



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

בחקירתה הנגדית-פרוטוקול מיום 6.1.15, עמ' 5 שורות 28-35). וכן- "בחו"ש 11/12 חתמתי עם עמידר על הסכם מכר (להשלמת העסקה משנת 2008) לפיו רכשתי את קומת המרתף (ראה בסעיף 13 לתצהירה זה). דברים דומים העידה גם בחקירתה הנגדית- "נכנסתי לתהליכים לרכוש את החלל מתחת לבית שלי מעמידר ונתנו לי את זה ב-2009..." (ראה בעדותה, עמ' 6 שורות 5-6). באופן דומה הסבירה קליימן כי- "עיון באישור הזכויות שאני קיבלתי מעמידר מאשר שאני הבעלים של הדירה וכן של בור המים, אשר נרכש מעמידר בהשלמת העסקה מיום 28.6.12" (ראה סעיף 15 לתצהירה).

44. דברים דומים עלו גם מעדותו של משה מזרחי, סגן מנהל מרחב בעמידר (להלן: "מזרחי"). מזרחי אישר כי גם מנקודת ראותה של רשות הפיתוח נמכר לקליימן בור המים - "השלמת העסקה התייחסה לבור המים שנמצא בקומת מרתף, כחלק מתת חלקה 8" (ראה בעדותו, עמ' 2 שורות 21-22). מזרחי אישר גם כי הסכם השלמת העסקה נחתם על רקע גילוי של בור המים, כמו שקורה לא אחת בבניינים ישנים. בהקשר זה העיד כי: "בורות קיימים בבניינים ישנים מקדמת דנא, מצויים בבניינים אלו בורות מים מיום הקמת הבניין, למרות שמגלים אותם בתקופות מאוחרות יותר, ואז מוכרים אותם לדיירים. בפרט באיזורי מוסררה, קטמון הישנה, כמעט בכל בניין התגלו בורות מים ואז ביצענו השלמות עסקה" (ראה עמ' 2 לעדותו שורות 25-27). מזרחי הסביר בעדותו את הרציונל לשימוש במונח "זכויות בניה" בהסכם המכר, על אף שלמעשה נמכר בור המים כחלק מהדירה - "ביחסים של רשות הפיתוח, דיירים שרכשו מבצעים תוספות בניה שלפעמים לא מקבלים עליהם היתרים, או שהבורות מים לא קיבלו היתר או לא נמצאים בתיק העירייה, רשות הפיתוח לא רוצה לקחת אחריות ולמכור ולהגיד ממכר, היא הופכת את זה לזכויות בניה ואומרת אני מוכרת לך בעצם זכויות בניה ולך תוציא היתר בניה למקום הזה, אם צריך היתר כמובן..." (ראה בעמ' 2 שורות 25-39). עם זאת הדגיש מזרחי בעדותו כי לא נמכרו לקליימן זכויות בניה נוספות אלא למעשה נמכר לה שטח בנוי על זכויות הבניה שבאופן טבעי מתווספות לבניין מעצם קיומו של השטח הבנוי. בהקשר זה הסביר למשל מזרחי ביחס לדירת קליימן כי- "יחידה מס' 8, המרתף שאותו ביצענו השלמת עסקה, היה קיים בבניין, לכן שנעשה חלוקה של הבית המשותף הוא יימנה כשטח בנוי שממנו יצאו לפועל זכויות הבניה, הוא ייספר בשטח הבנוי של כל הבניין" (ראה בעמ' 11 שורות 23-26). עוד הבהיר מזרחי בהקשר זה כי- "כשמכרנו את בור המים לא מכרנו את זה כזכויות בניה למגורים, אלא בור מים שהיה קיים בבניין. לא יודע אם זה גורע או לא גורע מהשטח, העירייה תגדיר את זה איך שהיא מבינה. לצורך המונח זכויות בניה נכנסו להסכם, כיוון שעמידר מתייחסת לכך שהדייר שיפץ את הדירה והשקיע כסף ואנו מתייחסים לזה כדרך חישוב. ערך של זכויות בניה הוא הרבה פחות משטח בנוי. אם הייתי מעריך את המרתף כבניה למגורים זה היה שווה הרבה יותר. היא הוערכה כבור מים ועמידר הפנתה את הדיירים להוציא היתר" (ראה בעמ' 12 שורות 41-46).

45. לפיכך יש לקבוע כי בור המים נמכר כעסקת השלמה לדירת קליימן (הנתבעים לא העלו כל טענה בנוגע לתוקפה ותקפותה של עסקת מכר זו, ועל כן הנחתי היא כי היא תקפה. המחלוקת נגעה לטיב הזכויות שרכשה קליימן, להבדיל מליכולתה המשפטית של רשות הפיתוח למכור).



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

46. למעשה, בור המים נמכר כחלק נוסף מדירת קליימן, ועל כן עמידר מכרה בור קיים, שהיה כבר בנוי, על זכויות הבנייה שהוא מקנה. בהקשר זה אישר מזרחי בעדותו כי מה שנמכר לקליימן הוא בור ללא זכויות בניה (ראה עמ' 8 שורות 43-45). מזרחי הבהיר עוד כי: **"הבור לא היה צריך זכויות בנייה ולא נמכרו בו זכויות בנייה"** (עמ' 9 שורה 24). מזרחי הסביר כי לא נמכרה תוספת זכויות בניה במסגרת עסקת המכר של בור המים, אלא שמדובר בשטח **בנוי** נוסף שנמכר (ראה שם, עמ' 11 שורות 23-26).
47. הנתבעים אשר טענו כי הכשרת בור המים למגורים גורעת לכאורה מזכויות הבניה המוקנות ליתר בעלי הדירות לא ביססו טענתם זו בכל ראייה.
48. **מהאמור לעיל עולה כי הוספת בור המים לדירת קליימן איננה בגדר הרחבה בה דן סעיף 71ב לחוק. הן משום שלא מצורף חלק פיסי כלשהו מהרכוש המשותף לדירת קליימן והן משום שלא נעשה שימוש באחוזי הבניה של יתר בעלי הדירות בהקשר זה. לפיכך, ממילא לא ניתן לראות בהוספת בור המים כ"הרחבה דומה".**
49. למעלה מן הצורך אציין כי אף אם היה ניתן לראות בהוספת בור המים לדירת קליימן כ"הרחבה", בין אם משום שהיה מדובר ברכוש משותף ובין אם משום שלשם הכשרתו כשטח עיקרי היה צורך לנצל את זכויות הבניה המוקנות ליתר בעלי הדירות- אין מדובר כלל ב"הרחבה דומה". אנמק.
50. תחילה יש להידרש להרחבה המבוקשת בדירת הנתבעים. ההרחבה המבוקשת עניינה בהיתר בניה לתוספת של **134.9 מ"ר** לדירת הנתבעים, באמצעות הרחבת דירתם אל עבר שטח הגג המשותף. מדובר בתוספת בניה על שטח הגג המשותף של מבנה 2 כולו, באופן בו תיבנה למעשה קומה נוספת, ומעליה ייבנה גג רעפים. קומה חדשה זו שתיבנה על הגג, תתווסף לדירת הנתבעים כחלק בלתי נפרד ממנה. משמעה של ההרחבה המבוקשת היא כי לדירתם של הנתבעים, שהיא במקורה בשטח של 120 מ"ר יתווסף שטח רצפה של 134.9 מ"ר, שאינו דבר של מה בכך, ובסך הכל תחלוש דירתם על שטח של 254.9 מ"ר. כאמור, משמעה של הרחבה זו היא שימוש בכל שטחו של הגג המשותף הקיים היום, כמו גם ניצול מלוא זכויות הבניה הקיימות כיום ביחס לבית המשותף, והוספת קומה שלמה למבנה 2.
51. בור המים שהתווסף לדירת התובעת 1, קליימן, הוא אמנם בשטח לא מבוטל ביחס לשטח דירתה המקורית. כאמור, בעוד שדירתה המקורית היא בשטח של 56.4 מ"ר (אם כוללים בה גם את המחסן הצמוד ששטחו 3.6 מ"ר), לאחר תוספת בור המים בשטח של 36.4 מ"ר, מגיעה הדירה לשטח של 92.8 מ"ר. אולם, בנסיבות העניין, כאמור, אינני סבורה כי יש לראות בכך "הרחבה דומה" ביחס להרחבה המבוקשת בדירת הנתבעים; מעבר לעובדה כי שטח ההרחבה של דירת קליימן קטן לאין שיעור משטח ההרחבה המבוקשת לדירת הנתבעים, הרי שגם אופיו שונה לחלוטין וממילא- השלכתו על מראהו וחזונו של הבית המשותף. הרחבה אל עבר מסד הבית המשותף, באופן חלקי בלבד, תוך שימוש בבור מים קיים איננו דומה להרחבה על כל שטחו



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

של גג הבית המשותף. הרחבה על פני גג הבית המשותף משנה כליל את אופיו וחזותו של הבית המשותף: בניין קטן ובעל אופי מיוחד בן שתי קומות הופך באחת לבניין בעל מימדים אחרים, המשתרע על פני 3 קומות מעל פני הקרקע, זאת נוכח בניית קומה נוספת ויצירת גג רעפים מעליו. בתוך כך חזיתו וחזותו משתנות, והוא הופך לבניין בעל צביון שונה. היקף ניצולו של הרכוש המשותף שונה לחלוטין, וכך גם הפגיעה ברכוש המשותף (ראה והשווה: תיק (מפקח י-ם) 234/11, **קליינמן נ' נדב** (פורסם באתר "משרד המשפטים").

52. בביקור שערכתי במקום התחדד למול עיני עוד יותר ההבדל הדרמטי בין הוספת בור מים לדירת קליימן (למעשה מדובר בהוספת חדר לדירה זו, המשמש בפועל כחדר שינה), אל מול בניה מסיבית שמשמעה קומה נוספת בבית משותף קטן ממדים בין שני קומות. אינני סבורה כי ניתן לראות דמיון כלשהו בין שני סוגי הבניה הללו, לא מבחינת היקף השטח המתווסף לכל אחת מן הדירות וקל וחומר שלא מבחינת היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף.

53. זאת ועוד. ברי כי היקף ניצול אחוזי הבניה לשם הכשרת בור המים למגורים (בהנחה שאכן יש צורך לנצל את אחוזי הבניה של כל בעלי הדירות ביחס להכשרת בור המים למגורים) קטן מהיקף אחוזי הבניה הנדרש לשם בניית קומה נוספת בשטח של 134.9 מ"ר על גג הבית המשותף. גם בהיבט זה אין המדובר בדמיון הנדרש לשם הוכחתה של "הרחבה דומה".

54. אפנה עתה לבחינת טיבה של ההרחבה בדירת התובעת 2 – אלון, והאם בנסיבות העניין יש לראות בה "הרחבה דומה".

55. אין חולק שבדירתה של התובעת 2 קיימת גלריה, המכפילה את שטח דירתה המקורית תוך פיצולה לשתי קומות. בניית הגלריה התאפשרה, לטענת התובעת 2, נוכח התקרה הגבוהה הקיימת בדירה.

56. כאמור, בעת הביקור במקום שערך כב' המפקח (כתוארו דאז) הייזלר, הסכימו הצדדים כי המדידות שנעשו במעמד זה יהיו את הבסיס לדיון בתובענה. באותה עת נמצא כי על מנת להיכנס לדירת התובעת 2, יש לרדת במדרגות שגובהן כ- 80 ס"מ (ראה פרוטוקול הביקור במקום מיום 17.12.14). העובדה כי מדובר בחפירה עלתה מעדותו של הנתבע 2, אבי ביטון, בתצהירו, בו הודגש בסעיף 10 כי **"לפני שהתובעות רכשו את דירותיהן, מפלס הרצפה של דירות אלו היה במפלס אחד עם הרחוב, ולא היו בהן גלריות ו/או מדרגות"**. דברים אלו אף מתיישבים עם עדותה של ליאת ביטון (עמוד 10 לפרוטוקול מיום 6.1.15 שורות 34-39, וכן עמוד 11 שורות 3-5) בקשר לחפירה שבוצעה בדירת אלון. דבריה אלו לא נסתרו או הופרכו.

57. מנגד, אלון לא הביאה כל עד מטעמה אשר יתמוך בגרסתה לפיה לא בוצעה כל חפירה וכי כל שעשתה היה כביכול להוסיף "גלריה" לדירתה. טענתה זו, אשר נסמכת על עדותה בלבד לא חוזקה בכל ראייה חיצונית. מנגד, נשמעו כאמור עדויותיהם של אבי ביטון וליאת ביטון מהן עולה תמונה שונה. יתרה מכך. כפי שמשקף מתשריט עמידר אשר צירפו התובעות עצמן לכתב התביעה, הוכפל שטח דירת אלון מ- 31.90 מ"ר, ל- 64.80 מ"ר. לא שוכנעתי כי רק בשל הקמת גלריה ללא חפירה כלשהי הוכפל שטח זה, ומסתברת בעיני יותר האפשרות כי אכן בוצעה בדירת אלון חפירה אל עומק הקרקע בגובה של כ- 80 ס"מ.

58. אף על פי כן, לא מצאתי, בנסיבות העניין, כי יש לראות בהרחבה זו כ"הרחבה דומה" להרחבה המבוקשת.



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

59. הנה כי כן, בעוד שאלון הרחיבה את דירתה בשטח של כ- 36 מ"ר, הנתבעים מבקשים למעשה להרחיב את דירתם בשטח הגדול פי ארבעה בקירוב. יתכן כי מסקנתי הייתה שונה לו החפירה שבוצעה בדירת אלון הייתה של קומה שלמה בשטח ניכר, אולם בפועל אין מדובר בחפירת "קומה", אלא בחפירה של כ- 80 ס"מ בלבד, כאשר אלון ניצלה למעשה את רום הגובה שבתוך דירתה שלה, מה שאיפשר לה בסופו של דבר לבנות את הגלריה.
60. ההבדל בין השטחים עליהם מבקשים הנתבעים להרחיב דירתם אל מול שטח ההרחבה של דירת אלון הוא משמעותי ביותר ואינו עולה, כאמור, כדי "הרחבה דומה". יתרה מכך, גם אם – כטענת הנתבעים – הוראות התכנית מאפשרות בניה על גג הבית לגובה מירבי של 1.75 מטר בלבד הרי שבניה כאמור המתפרסת על פני שטח כה גדול (כ- 135 מ"ר), היא משמעותית לאין ערוך מגלריה בשטח של כ- 33 מ"ר, ובפרט שגובה הגלריה שבדירת הנתבעת 2 (2.06 מ') אינו שונה מהותית מגובה הבניה האפשרית על גג מבנה 2.
61. כך התרשמתי באופן ברור גם מביקורי במקום. דירת אלון, אשר אכן הורחבה אל תחומי הרכוש המשותף, הורחבה במידה פחותה משמעותית מזו המבוקשת על ידי הנתבעים, וברי כי היקף ניצולו של הרכוש המשותף ומידת הפגיעה בו שונים לחלוטין ביחס להרחבה המבוקשת על ידי הנתבעים.
62. בהיבט זה- של השוני באופייה של הרחבת דירת אלון אל מול אופייה של ההרחבה המבוקשת- יפים נימוקיי בנוגע לדירת קליימן גם ביחס לדירת אלון.
63. היות ונמצא כי אין לראות בהרחבת דירת קליימן, כמו גם בהרחבת דירת אלון, "הרחבה דומה" להרחבה המבוקשת, הרי שאין לראות בהן כמי שמסכימות לה קונסטרוקטיבית, כאמור בסעיף 71ב(ג) לחוק.
64. הנתבעים לא הציגו הסכמות פוזיטיביות של בעלי דירות כלשהם בבית המשותף להרחבה המבוקשת- בין אם במבנה 2 בלבד ובין אם גם במבנה 1. משכך, בין אם נראה את "יחידת הבסיס" של הבית המשותף, ממנה יש לגזור את אחוז ההסכמות הנדרש בסעיף 71ב לחוק, ככזה המונה את שני המבנים גם יחד ובין אם נראה אותה כמבנה 2 בלבד, לא עומדות לרשות הנתבעים ההסכמות הנדרשות בדין על מנת לבצע את ההרחבה המבוקשת.
65. ודוק: גם אם יש ממש בטענת הנתבעים כי התכנית מאפשרת את ניצול אחוזי הבניה הקיימים רק לטובת בנייה בגג, ולפיכך ממילא אין במימוש זכויות אלו בכדי לגזור מיכולתן של התובעות לעשות בהן שימוש לצורך הרחבת דירותיהן, אין בכך לכדי לאפשר לנתבעים לבצע את הבניה ללא ההסכמות הנדרשות בדין.
66. נטיית הפסיקה היא לקבוע כי זכויות הבניה הן זכויות המצויות בבעלות משותפת של בעלי הדירות בבניין, אף שאינן בגדר חלק מהרכוש המשותף, וזאת כל עוד אין הוראה אחרת בכל הסכמי המכר או בתקנון המוסכם. זכויות הבנייה הן זכויות בעלות ערך כלכלי ממשי. לפיכך, ניצולן על-ידי בעל-דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות (ראו: ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' פרוץ דוד שרון, [פורסם בנבו] בעמ' 36 (27.8.2009), ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן, [פורסם בנבו] בעמ' 13 (18.2.2010); ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2) 807, 811-812 (1980), ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4) 673, 680



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

(1986), ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1) 469, 475 (1996), ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389, 394 (2000).

67. אשר על כן, לשם ניצולן של זכויות הבניה יש צורך בקבלת הסכמת בעלי הדירות כדין, וזאת אף אם בעלי דירות אחרים לא יכולים בעצמם לעשות שימוש בזכויות אלו לשם הרחבת דירותיהם. לפיכך, ובהיעדר ההסכמות הנדרשות בדיון, יש לאסור את הבניה המבוקשת.

68. מעבר לדרוש אציין כי לו היו בידי הנתבעים את הסכמות בעלי הדירות כדין, ניתן היה לאפשר, מן הבחינה הקניינית, את ההרחבה המבוקשת והיה מקום לדחות את טענות התובעות לפגיעה בזכויות הבניה היחסיות שלהן.

69. כאמור, סעיף 71 ב(ב) לחוק קובע כי גם במצב בו קיימות ההסכמות הנדרשות בסעיף 71ב(א) לחוק לשם ביצוע ההרחבה, היינו הסכמת 3/4 מבעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהן, עדיין לא ניתן לקבל החלטה תקפה בדבר הרחבה כזו ככל ש- "יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה".

70. אין חולק כי מלוא זכויות הבניה הקיימות כיום לבית המשותף, בהתאם לתכנית, עתידות להיות מנוצלות על ידי הנתבעים, אם וכאשר תמומש ההרחבה המבוקשת. לכאורה, לא תיוותרנה זכויות בניה לניצול ליתר בעלי הדירות, ועל כן כביכול מתקיימת הוראת סעיף 71ב(ב) לחוק. דא עקא, כי שני הצדדים הסכימו שעל פי התכנית הקיימת ניתן לנצל את זכויות הבניה הקיימות ממילא רק לשם בניה על גג הבית המשותף. במצב דברים זה, ניצול זכויות הבניה כמבוקש אינו עתיד לשנות מהמצב הנוכחי בכל הנוגע לזכויות היחסיות של התובעות להרחבה.

71. טענת התובעות כי מנוצלות במסגרת ההרחבה המבוקשת גם זכויות בניה המוקנות להן על פי דין נכונה היא, כאמור לעיל. אולם, אין בעובדה זו כשלעצמה בכדי למנוע את ההרחבה המבוקשת. המחוקק קבע בסעיף 71ב לחוק את המנגנון בהתקיימו יכול בעל דירה לעשות שימוש בזכויות הבניה של יתר בעלי הדירות גם ללא הסכמת כולם- וזו הסכמת 3/4 מבעלי הדירות להם 2/3 מהרכוש המשותף (לעניין הקביעה כי הסכמה ברף זה נוגעת גם לחלוקת זכויות הבניה כאמור ראה עניין פל). על כן, על מנת שבעל דירה אשר לא הסכים להרחבה, או אף הסכים אולם משמעות הסכמתו היא כי דירתו לא ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף, לא יצא כשידו על התחתונה- נקבעו בחוק הסדרים הנוגעים לפיצוי על דרך של "תשלומי איזון" בסעיף 71ב(ד) לחוק. לפיכך, לא מצאתי בסיס בטענת התובעות לפיה די בעובדה כי זכויות הבניה היחסיות שלהן נפגעות בכדי שלא לאפשר לנתבעים את ביצוע ההרחבה המבוקשת.

72. יתרה מכך. כשלעצמי תהיתי אם בעובדה שהתכנית קובעת מגבלת גובה של 3 קומות לכל היותר בבניין (ראה סעיף 9 (ג) לתכנית), יש כדי לפגוע בזכויות הבניה היחסיות של התובעות להרחבה זאת משום שלכאורה, לו תמומש ההרחבה המבוקשת באמצעות בניה בגג, ייתכן והבניין יגיע למגבלת 3 הקומות ועל כן עלולה להימנע מהתובעות אפשרות ההרחבה כדין אל עבר קומה נוספת, היא קומת המסד. לאחר ששקלתי בעניין הגעתי לכלל מסקנה כי אלו אינם פני הדברים. ראשית, משום שסעיף 9 (ה) לתכנית קובע כי "מרתפים קיימים כולל אלו המשמשים למגורים, לעת הפקדתה של תכנית זו, לא יחושבו במניין הקומות כאמור לעיל..." ומבלי



משרד המשפטים לשכת המפקח על רישום המקרקעין ירושלים

לקבוע בכך מסמרות, יש לכאורה יסוד לראות בבור המים גם הוא כמרתף העונה על הוראות סעיף זה. שנית, שימוש בבור המים לצורך מגורים – כמבוקש בדירת קליימן, או חפירה של 80 ס"מ אל עבר הקרקע בדירת אלון, אינו מהווה בהכרח בנייה של "קומה נוספת". מטעם זה גם לא מצאתי שיש פגיעה בזכויות הבנייה היחסיות של התובעות להרחבה, כנדרש בסעיף 71ב(ב). ממילא גם התובעות לא טענו כן במפורש, והדברים נאמרים רק בגדר למעלה מן הצורך.

73. יש להוסיף עוד כי מצאתי לדחות את טענת התובעות כי עם ביצוע ההרחבה המבוקשת תיפגענה זכויותיהן שכן ערך דירת הנתבעים יעלה בעוד שערך דירתן ירד. בהעלאת ערכה של דירת הנתבעים כשלעצמה לא מצאתי משום פגיעה כלשהי בדירת הנתבעות. ממילא, טענתן כי ערך דירתן ירד נטענה בעלמא ולא גובתה בחוות דעת מומחה או כל ראייה אחרת.

74. באשר לסוגיית תום הלב- בעניין זה עליי לבחון האם חל על התובעות השתק או שהן מנועות מלהגיש תביעה זו, שכן יש לראותן כמי שעושות שימוש לרעה בזכותן הקניינית. נושא איסור שימוש לרעה בזכות במקרקעין נדון רבות בהלכה הפסוקה, כשבפסק הדין המנחה בסוגיה נקבע כי קיימת חובה לממש זכויות בדין, לרבות זכויות קנייניות – בתום לב (ור' בעניין זה רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה (1), 199).

75. כך גם נקבע זה מכבר כי לבעל זכות קניינית אין את החרות להתנגד לכל מיזם של שכנו באופן סתמי ונטול הנמקה, וכי רק התנגדות בלתי הוגנת הנעוצה בקינטור, או התנגדות שיש בה לעמוד בסתירה לעקרונות היסוד של שיטת המשפט, תהא כזו אשר נכון יהיה להתעלם ממנה ולא להביאה במסגרת מניין ההתנגדויות לבניה המבוקשת ברכוש המשותף (ר' ע"א (חי) 835/08 **נטלה נ' פרי** [פורסם ב"נבו"] 18.11.2009, עש"א (חי) 17181-05-11, **גורי אברהם נ' יאיר פדאל** [פורסם בנבו] 20.9.11). ואולם, על הנתבע, כמי שמהווה מיעוט, להוכיח שהתנגדות התובעים היא אכן סתמית וקנטרנית (ר' למשל עש"א (חי) 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד** מיום 7.6.2013).

76. במקרה דנן לא מצאתי כי התנגדות התובעות מהווה חוסר תום לב המצדיק את התערבותי. התובעות אף משכו את הערר שהגישו לוועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה בקשר להיתר הבניה שניתן, ובחרו לנהל את התובענה בפני מתוך מטרה להגן על זכויותיהן הקנייניות. לא מצאתי כי יש בטעמי התנגדותן חוסר הגינות, וודאי לא כי התנגדותן מנוגדת לעקרונות היסוד של השיטה. על רקע נסיבות העניין הפרטני, אין די בעובדה שהתובעות הרחיבו את דירותיהן, גם אם בהיעדר היתר בניה כדין (לפחות אותה עת), בכדי להוות טעם המצדיק להתעלם כליל מטענותיהן. במקרה הנדון עסקינן במימוש זכויות בניה נרחבות על גג הבית המשותף, כאשר התובעות כבעלות חלק מזכויות בניה אלו, זכאיות להביע עמדתן, וחששן מפני הפגיעה בזכויותיהן הקנייניות. אינני סבורה כי יש בטעמים אלו משום חוסר תום לב העולה כדי הצדקה לראות בהן כמי שמנועות או מושתקות מלהגיש תביעה זו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ה. הערות בטרם סיום

77. תוצאת פסק הדין היא שהנתבעים או מי מהם מנועים מלהרחיב את דירתם ולממש את היתר הבניה המצוי בידם לשם כך. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי נראה שקיים פתרון למחלוקת בין הצדדים – פתרון אשר הועלה במהלך הדיון בהליך לא אחת, אולם נדחה על ידי ב"כ התובעות.
78. מהמסמכים שהוצגו בפני וגם מעדותה של התובעת 1 עולה כי קיימת הסכמה מסוימת מצד התובעות להביא את המחלוקת על פתרונה בסעד כספי: **"על פני הדברים נראה כי שאכן אם ישלמו לנו כסף, לכולנו, כפי שנראה לנו לא תהיה לנו התנגדות לבניה"** (עמוד 8 לפרוטוקול מיום 6.1.2015, שורות 29-30).
79. טוב יעשו הצדדים לו יעשו מאמץ להגיע לעמק השווה, באופן אשר יאפשר את ביצוע ההרחבה המבוקשת אל מול תשלומים הולמים וראויים לתובעות.

ו. סוף דבר

80. משאלו פני הדברים, ולאור המוסבר לעיל, אין לי אלא לקבוע כי לעת הזו, אין לנתבעים כל אפשרות, לבצע את ההרחבה המבוקשת בבית המשותף (מבנה 2).
81. התביעה למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להרחיב את דירתם אל עבר גג הבית המשותף, מתקבלת. נאסר על הנתבעים לבצע כל פעולת בנייה בגג הבית המשותף למעט בנייה בתוך דירתם הנוכחית.
82. בנסיבות העניין, יישאו הנתבעים בהוצאות התובעות ושכר טרחת עורך דינם בסך כולל של 5,000 ש"ח.

ניתן היום, י"ח תמוז תשע"ו, 24 יולי 2016, בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת על רישום מקרקעין